



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5868/2016/2/CA1

Paraná, 25 de octubre de 2017.

Y VISTOS, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Presidente; el Dr. Mateo José BUSANICHE, Vicepresidente; y la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Jueza de Cámara, en el Expte. N° FPA 5868/2016/2/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACIÓN DE RODRIGUEZ, CINTIA ANAHÍ EN AUTOS RODRIGUEZ, CINTIA ANAHÍ POR INFRACCIÓN LEY 23.737"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Paraná, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Daniel Edgardo Alonso dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de la imputada Cintia Anahí Rodríguez, contra la resolución obrante a fs. 1/4 vta., en cuanto decreta el procesamiento de la nombrada por el hecho por el cual fuera indagada, tenencia simple de estupefacientes, previsto y reprimido por el art. 14, 1ra. parte, de la ley 23.737, y de conformidad a los arts. 306 y 308 del CPPN. El recurso fue concedido a fs. 10.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 18 y vta., compareciendo en dicha oportunidad el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante, Dr. Alejandro Joaquín Castelli, en defensa de la imputada Cintia Anahí



Rodríguez, y el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo C. M. Álvarez; quedando los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, el Dr. Castelli refiere al hecho que da inicio a la causa, y se remite al escrito recursivo. Relata el devenir del procedimiento, y entiende que la Fuerza policial tuvo mucho tiempo para informarle al juez el desarrollo de la investigación y no lo hizo. Sostiene que no se actuó conforme el art. 230 bis del CPPN.

Afirma que el oficial Salim reconoce en su testimonial que la Fuerza policial tenía información de que Rodríguez viajaba, y alega que montaron una "farsa" a fin de detener la marcha de su asistida. Cita el fallo Fernández Prieto de la C.S.J.N. y destaca que el procedimiento no se puede legitimar por el resultado.

Por otra parte, indica que Rodríguez fue vista por el médico de la Cámara, quien dice que es una consumidora ocasional.

Solicita, en primer lugar, se decrete la nulidad del procedimiento, la detención, requisa y secuestro de la droga. Subsidiariamente, se tipifique la conducta en art. 14, segundo párrafo, y se decrete la inconstitucionalidad.

Hacer reserva de recurrir en Casación.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5868/2016/2/CA1

b) A su turno, el Sr. Fiscal General señala que Rodríguez fue invitada a exhibir sus pertenencias, oportunidad en la que extrajo un pequeño bulto que arrojó como resultado marihuana, que había sido adquirido en la ciudad de Paraná.

Indica que no se entiende que ocurrió en Paraná, porque se supone que se entrecruzaron llamadas telefónicas, que fue objeto de un seguimiento, que también se cursó una comunicación a los pares de Diamante. Destaca que las reglas de juego imponen la observancia de ciertos pasos bajo el contralor del Poder Judicial.

Indica que la Fiscalía dispone de pocos elementos como para poder adherir al planteo de la Defensa. Asevera que lo que resta es el principio de confianza que cabe reconocer en los funcionarios públicos, destacando que puede suponerse que la forma en la que se redactó el acta no es fiel a lo que sucedió, sino que se trataba de actos aislados. Indica que existiendo versiones acerca de lo que ocurrió antes de que fuera interceptada Rodríguez, corresponderá profundizar esta pesquisa para poder proponer una salida como la que aquí se propicia.

Solicita se confirme la resolución, destacando que el planteo debe ser llevado al ámbito correspondiente en una incidencia puntual.

II- a) Que, en primer lugar, la defensa postula la nulidad de la detención y requisa de la



imputada Rodríguez y de todos los actos que han sido su consecuencia, entendiendo que no se presentaron en el caso los requisitos exigidos por el art. 230 bis del CPPN. Subsidiariamente, plantea el cambio de calificación de la conducta de su asistida, por la figura del art. 14, segunda parte, de la ley 23.737, y se declare su inconstitucionalidad para el caso concreto.

b) Corresponde al Tribunal entonces, analizar si en el caso, se habrían configurado los recaudos que prevé el art. 230 bis del CPPN y que justifiquen el procedimiento llevado a cabo por la Fuerza de seguridad en su tarea de control.

Debo señalar que analizaré lo expuesto, dejando a salvo mi postura en relación a que la Policía de la Provincia de Entre Ríos carece de facultades para la aplicación directa de la legislación procesal nacional, excepto cuando se encuentre cumpliendo funciones delegadas por el Magistrado Federal.

Sentado lo expuesto, debo señalar que el art. 230 bis del CPPN reclama, para legitimar el procedimiento efectuado por funcionarios de la policía y fuerzas de seguridad, sin orden judicial, el concurso de dos elementos, a saber: a) la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas respecto de persona o





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5868/2016/2/CA1

vehículo determinado; b) en la vía pública o en lugares de acceso público. Asimismo, el art. 230 bis, *in fine*, del CPPN dispone que *“tratándose de un operativo público de prevención podrán proceder a la inspección de vehículos”*.

Así se ha dicho que *“El inc. a) tiene una amplitud que para mantenerla dentro de la razonabilidad requiere hacer objetivas -exteriorizarlas para que no permanezcan en la subjetividad de quien la ordena- las circunstancias anteriores o coetáneas que respalden la requisa de la persona o vehículo. El inc. b) se refiere sólo al lugar -vía pública o lugar de acceso público-. La letra de la ley impone la concurrencia simultánea de ambos recaudos...”* (D’Albora, Francisco J., “Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado”. Octava edición corregida, ampliada y actualizada por Nicolás F. D’Albora. Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2009, pag. 412).

En este sentido, se ha sostenido también que *“...la legitimidad del accionar policial no debiera subordinarse de modo fatal a la preexistencia de un ‘estado de sospecha’, tal como ha sido nominado con dudoso acierto por la jurisprudencia sino -mejor- a la comprobación de un marco previo circunstancial sobre cuya base pueda extraerse material empírico para elaborar un enjuiciamiento objetivo de los motivos invocados por*



la autoridad, cuando decide injerirse preventivamente sobre la esfera individual" (L.S. Crim. 2.003-II-571; entre otros).

Con estas pautas, corresponde analizar si los datos aportados por el personal de la Policía de Entre Ríos acerca del modo en que sucedieron los hechos, constituyeron un punto de partida válido para la iniciación de las actuaciones.

Al respecto, del análisis de las constancias de la causa (cfr. acta de procedimiento de fs. 1/2 y de las testimoniales civiles y de actuación en sistema Lex100), surge claramente que la motivación del abordaje y requisa de la imputada Rodríguez en la vía pública de la ciudad de Diamante, obedeció en primer lugar a la información que habría recibido el personal policial, que diera inicio a una supuesta investigación previa que habría realizado la Fuerza.

Advierto del devenir de los hechos, que el personal policial durante el tiempo que llevó la supuesta pesquisa a partir de la información obtenida, contó con más de dos horas (lo que supone un viaje de ida y vuelta de Diamante a Paraná) para requerir judicialmente la requisa de la imputada Rodríguez; y no realizó esfuerzo alguno a tales efectos.

Que el proceder expuesto, se opone al carácter de autorización excepcional que debe





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5868/2016/2/CA1

revestir la medida intrusiva prevista en el art. 230 bis del CPPN, surgiendo puntualmente del acta que: "... personal de la división a su cargo recibe información que habría viajado hacia la ciudad de Paraná la ciudadana Rodríguez a comprar material estupefaciente, por tal motivo le solicita colaboración al personal de la dirección de toxicología para que si podían seguir a la femenina en la ciudad de parana a los lugares donde se dirigía, informándole alrededor de las 17:15 que la ciudadana Rodríguez Cintia habría toma un colectivo en calle ramirez -sic- frente a villa 351, por tal motivo personal de su división realiza un operativo de identificación de persona con la finalidad de interceptar a esta femeninal -sic-, dicho operativo se realiza con personal femenina -sic- la Sgto Becker Vanina, interceptando a la ciudadana Rodríguez Cintia en las calle antes mencionada, la cual al momento de solicitarle que exhibiera sus pertenencias, la misma saca del bolsillo derecho de la campera de cuero de color marrón que lleva consigo, un bolsa de nylon de color verde, la cual contiene en su interior un trozo compactado de color verde amarronado, de características similares a la marihuana, procediendo a darme intervención -sic- ..." (cfr. acta de procedimiento en sistema Lex100).

Fecha de firma: 25/10/2017

Alta en sistema: 26/10/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30393818#191831031#20171025123801400

En el mismo sentido, manifiesta el agente Salim que: "...debido a que tenían conocimiento de que la ciudadana había ido a la ciudad de Paraná, a comprar estupefaciente, informan a la Dirección primero para que la siguieran a los lugares adonde iba a la ciudad de Paraná, tomando el colectivo la ciudadana Rodríguez enfrente a la Villa 351, eso me lo informa el jefe de investigaciones por eso la habían parado a esa ciudadana. Es ahí donde se le solicita exhiba sus pertenencias..." (cfr. fs. 29 y vta. del principal).

De todo lo expuesto, y en concordancia con lo que se manifestara previamente, los motivos alegados por el agente Salim para actuar en uso de las facultades que le reserva el art. 230 bis del CPPN, no se encontraban presentes en el caso de autos, toda vez que el contexto en que éste procedimiento se materializara carece de aptitud para ser tenido en cuenta como hechos concomitantes que habiliten a la excepción a la regla prevista en el art. 230 bis del código adjetivo; destacándose que los funcionarios actuantes contaban con tiempo más que suficientes para solicitar la orden de requisa al Juez.

Que por todo lo dicho no puede convalidarse el procedimiento policial puesto en crisis, pues se advierte un claro avasallamiento de garantías constitucionales originado en que el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5868/2016/2/CA1

abordaje y requisa de la imputada, sin que se encontrara respaldada por elementos objetivos que “justifiquen la afectación a la libertad o al pudor de una persona en aras del descubrimiento de la verdad”. (CNCP, Sala II, “Martínez Walter E. s/ rec. de casación”, reg. 2535, causa 1980, rta. El 10/5/1999, voto Dr. Fégoli).

Ello, siguiendo la doctrina del Alto Tribunal según la cual “Si en el proceso existe un solo cauce de investigación y éste estuvo viciado de ilegalidad, tal circunstancia contamina de nulidad todas las pruebas que se hubieran originado a partir de aquel” (Fallos 310:2384), por lo que ni la detención ni la requisa ni los elementos secuestrados en consecuencia debieron haber dado inicio a la instrucción de la causa (cfr. Fallos 308:733, 310:1847, entre otros).

A mayor abundamiento cabe expresar que, la discusión ha sido abordada en repetidas ocasiones por la CSJN, en las que se destacó invariablemente que las normas de procedimiento penal e inclusive las leyes orgánicas de la policía, reglamentan la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional y prevén los casos y las condiciones bajo los cuales los agentes de las fuerzas de seguridad pueden arrestar a un individuo o practicar medidas que supongan injerencia en su ámbito privado, sin contar con una autorización judicial (del Voto disidente



del Dr. Zaffaroni en Fallos 333:1235, CS, "Munch Gustavo...", 3/08/2010 en La Ley online)

Es que, toda medida de coerción en el proceso penal, en tanto supone una injerencia estatal en derechos de rango constitucional, se encuentra sometida a restricciones legales destinadas a establecer las formas y requisitos que aseguren que esa intromisión no sea realizada arbitrariamente y que en última instancia pueda ser sometida al escrutinio imparcial de los jueces.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer lugar al pedido de nulidad interpuesto por la defensa de Cintia Anahí Rodríguez y, en consecuencia, declarar la nulidad del acta de procedimiento que da origen a estos actuados y de todos los actos que son su consecuencia, disponiéndose asimismo el sobreseimiento de la nombrada, en virtud de los argumentos expuestos.

El **Dr. Mateo José Busaniche**, dijo: dijo: Adhiere en lo sustancial a la solución propuesta por el Dr. Alonso

Ello por cuanto, la "información" que habría recibido el personal de la Jefatura Departamental Diamante, de que *"habría viajado hacia la ciudad de Paraná la ciudadana Rodríguez a comprar material estupefaciente"*, la cual dio lugar a que se solicitara la colaboración a la Dirección de Toxicología y, a la postre, a su intercepción y a la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5868/2016/2/CA1

solicitud de que exhiba sus pertenencias -tal como surge del acta de fs. 1/2 y del testimonio del agente interviniente Salim obrante a fs. 29 de los autos principales-, no basta para configurar las "circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente" permitan justificar dicha medida, sin la intervención del magistrado competente.

La **Dra. Cintia Graciela Gomez**, dijo: I..., II- Que encontrándose sellada la suerte del presente recurso, habré de manifestar brevemente mi voto disidente.

Con relación al planteo nulificante, la secuencia fáctica que permite ilustrar acerca del proceder de la Fuerza dentro de los parámetros que legalmente la habilitan y los motivos que dispararon su actuación, por el momento no ofrece fisuras y fue ratificada por los testimonios de agentes prevencionales -cfrse. actas obrantes en Sistema Lex 100-. Asimismo, de todo lo actuado se dio comunicación al Juzgado Federal.

De tal modo, siguiendo al Sr. Fiscal General, no se advierte por el momento de los elementos obrantes avasallamiento alguno de derechos constitucionales del debido proceso, sin perjuicio de que el planteo pueda ser profundizado y llevado al ámbito correspondiente.



En este sentido, dichas facultades de control y prevención del delito en la vía pública han sido ratificadas recientemente por la CSJN en autos "Recurso de hecho deducido por el Fiscal en causa Lemos, Ramón Alberto...", CSJ 183/2013-49-L, del 9/12/2015 y "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la CFCP en la causa Stancatti, Oscar...", CSJ 578/2014-50-S, del 24/05/2016.

En todo caso, será en la etapa del juicio donde corresponderá realizar una mensuración ajustada sobre los elementos de prueba con los que se cuenta.

Por lo expuesto, sostengo que ha de rechazarse la postulación de nulidad impetrada por la defensa.

III- Que en segundo término, la defensa solicita un cambio de calificación de la conducta, que aquella se encuadre en el art. 14, segunda parte, de la ley 23737 y se decrete la inconstitucionalidad de dicha figura, conforme las pautas del fallo "Arriola".

Que sobre el tema a decidir, se ha reiteradamente sentado que en los recursos deducidos contra el auto de procesamiento la cuestión concerniente a la calificación de la conducta, atento a su provisoriedad, resulta -en principio- ajena a esta instancia.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5868/2016/2/CA1

Así se ha sostenido que, “para ello, se atiende especialmente, a que... la cuestión es propia, en el caso, del llamado principio ‘iura novit curia’, dado que los hechos... fueron comunicados siempre... de un modo amplio, preservando su derecho de defensa, por lo que el progreso de la causa, permitirá, en su caso, que la intimación sea rectificadora” (cfr. L.S.Crim. 2013-I-0431, entre muchos otros).

Sin embargo, hemos entendido también que si la revisión de la calificación jurídica tuviera alguna incidencia en la modificación de una situación de privación de libertad, ello constituiría motivación suficiente para dar tratamiento a la cuestión en esta instancia.

En el caso, la eventual mutación de la figura penal endilgada a la imputada carece de entidad para modificar la situación de hecho - libertad- en la que aquella se encuentra.

En efecto, la circunstancia de que el sustrato fáctico fuera correctamente comunicado a aquella (cfr. declaración indagatoria obrante en Sistema Lex 100), viabiliza la eventual revisión de la calificación de su intervención en el momento procesal correspondiente, salvaguardando el derecho de defensa y, paralelamente, asegurando el principio de congruencia.



Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa y confirmar la resolución apelada.

En mérito al resultado del Acuerdo precedente, por mayoría, **SE RESUELVE:**

Decretar la nulidad del acta de procedimiento obrante a fs. 2/3 de los autos principales y de todos los actos que son su consecuencia, y disponer el sobreseimiento de Cintia Anahí Rodríguez, de demás condiciones personales obrantes en autos, en función del art. 336 inc. 2º del CPPN., con la expresa declaración de que la formación del presente no afecta el buen nombre y honor de que hubiere gozado (art. 336 último párrafo del CPPN.).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ
EN DISIDENCIA

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

